

1500091-33.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... os réus Rhuan e Tiago negaram a prática de tráfico. Rhuan alegou ter sido abordado sem qualquer droga em seu poder. Tiago, embora negue o tráfico, admite ter comprado para uso pessoal 16 ou 17 pinos de cocaína, com os quais foi abordado e preso.

Daniel, por sua vez, admite a posse de 211 porções de cocaína, alegando que estaria guardando em sua residência em troca de 300 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-33.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-33.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RHUAN DE CAMARGOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face dos acusados RHUAN DE CAMARGOS, DANIEL RODRIGO FERREIRA VAZ e TIAGO ANDRÉ DOS SANTOS, já qualificados nos autos, como incurso no art.33, da Lei 11.343/2006.

Os réus foram notificados (fls.199/201).

Defesa Preliminar apresentada às fls.208/222.

A denúncia foi recebida às fls.228/229.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e os réus foram interrogados.

As partes debateram.

Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu instauração de incidente de dependência toxicológica e, no mérito, a absolvição por falta de provas.

É a síntese.
DECIDO.

Preliminarmente, indefiro o pedido de instauração do incidente acima mencionado.

Isso porque, como se sabe, o julgador não está obrigado a determinar que se faça o exame de dependência toxicológica, pois a ele cabe a faculdade de determinar ou não a sua realização, caso haja a possibilidade de inimputabilidade do acusado, ainda que de forma reduzida.

É somente imprescindível a instauração quando houver dúvida acerca da insanidade ou da dependência toxicológica.

Confira-se, a esse respeito, julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“O Código de Processo Penal obriga ao exame quando houver dúvida sobre a insanidade e não quando a defesa o requeira. Assim, o Magistrado somente deferirá o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental quando presentes indícios de perturbação ou algum motivo, pelo menos, para duvidar da normalidade psíquica, que é regra geral” (TACRIM-SP, JUTACRIM 84/2006).

Lembre-se que mero uso de drogas, ainda que prolongado, não implica necessariamente em dependência química.

No mais, conforme entendimento majoritário no STJ (HC 258463/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma) a mera suspeita ou afirmação de que o acusado seja usuário de substâncias ilícitas não justifica a realização de exame em análise.

Vejamos:

“A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias entorpecentes não obriga o magistrado a realizar o exame de dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua realização” (RHC 14.789/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª. Turma, julgado em 07.10.2003, DJ 10.11.2003 p. 198)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes Preliminar - Nulidade decorrente do indeferimento de realização de exame toxicológico Inocorrência. Ausência de indícios de que a corré Eliane era inimputável pela dependência química. Prescindibilidade da perícia”. (TJSP, 4ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0001016-16.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Camilo Léllis, São Paulo, 31 de janeiro de 2017).

Ademais, como lecionava Borges da Rosa: “a efetuação de exames desnecessários ao esclarecimento da verdade atentaria contra os requisitos superiores do processo: celeridade, simplicidade e moralidade” (TJSP, trecho de acórdão da apelação criminal nº 0003100-19.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Lauro Mens de Mello, citando decisão extraído do livro Jurisprudência e Doutrina Criminais, Mohamed Amaro, vol. II, 1979, p. 895).

No mérito, a absolvição é de rigor. Vejamos:

Interrogados, os réus Rhuan e Tiago negaram a prática de tráfico. Rhuan alegou ter sido abordado sem qualquer droga em seu poder. Tiago, embora negue o tráfico, admite ter comprado para uso pessoal 16 ou 17 pinos de cocaína, com os quais foi abordado e preso.

Daniel, por sua vez, admite a posse de 211 porções de cocaína, alegando que estaria guardando em sua residência em troca de 300 reais. Diz que passava por penúria financeira. Nega que tenha sido abordado em via pública.

Os três negam ter sido abordados juntos.

Os guardas municipais, de outro lado, afirmaram em juízo o recebimento de delação sobre a prática de tráfico em local já conhecido por tal prática espúria. Lá chegando, avistaram os acusados Rhuan e Tiago. Em seguida, Daniel chegou, oportunidade em fizeram a abordagem. Não avistaram atitude típica de venda de drogas. Relatam ainda a apreensão de drogas com os três denunciados, encontradas em revista pessoal, além de dinheiro. Dizem que Daniel admitiu ser "gerente" do ponto de tráfico.

São as provas. A absolvição é de rigor.

Com efeito, em que pese ser possível que guardas municipais, como qualquer cidadão, realizem prisões em flagrante (art. 301, do CPP), por não ostentarem atribuições de investigação ou patrulhamento ostensivo, funções típicas das Polícias Civil e Militar, tenho como nula a prisão feita nestes autos e, como consequência, também nulas as provas dela decorrentes.

Nesse sentido, prisões feitas por guardas civis devem ser restritas àquelas em que exista a certeza visível do cometimento do delito, sendo-lhes vedada atividades investigativas em especial quando baseadas em "denúncias anônimas" e com revistas em possíveis criminosos, tal qual ocorreu "in casu".

No presente caso, é da denúncia e dos depoimentos colhidos na fase de investigação que os guardas, extrapolando suas atribuições, ainda que de boa-fé, receberam delação apócrifa sobre a prática de tráfico com a indicação do local e passaram a realizar patrulhamento ostensivo e investigativo, logrando encontrar os réus em via pública no local indicado.

E mais, com base exclusivamente na denúncia recebida (digo, sem que tenham sido flagrados em conduta típica de tráfico), foram abordados e revistados, encontrando em poder dos denunciados as drogas apreendidas.

Assim sendo, resta evidente que não detinham certeza visual do crime, o que impede que realizem prisão flagrancial ou revista pessoal.

Se tivessem avistado os réus em franca atitude de traficância, nenhuma mácula haveria na abordagem e prisão feita pelos guardas. Entretanto, não é essa a situação dos autos.

Em verdade, como se vê, os guardas realizaram patrulhamento ostensivo e atividade investigativa para desvendar os supostos autores do crime informado por delator anônimo, funções que escapam da esfera de atribuição da Guarda Municipal (art. 144, §8º, da CF/88).

Lembre-se que o princípio da estrita legalidade determina que o agente público só pode fazer o que estiver expressamente previsto em lei, e os guardas municipais não estão autorizados a investigar crime, muito menos da forma como fizeram neste caso, sem terem visto ou presenciado qualquer atitude criminosa do réu, em verdadeiro

combate ostensivo ao crime.

De fato, no caso concreto, não havia prévia situação de flagrante delito que permitisse a atuação da Guarda Civil Municipal, visto que não foi visualizado pelos guardas o crime sendo cometido, tendo ocorrido diligências, abordagem e buscas pessoais e no local, após terem sido “acionados, via rádio”.

Dessa forma, ilegal e inconstitucional a ação dos guardas civis municipais na espécie, o que não permite, nesse momento, ainda que de ofício, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, oportuna trazer à baila julgados do E. Tribunal Paulista:

"(...) Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Civis Municipais. Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil. Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal. Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida. Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência.". (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (TJSP, Apelação Criminal nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais e em verdadeira atividade investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

Aliás, também apontam na mesma direção os julgados do E. STJ sobre prisão/investigação por guardas municipais. Vejamos:

"(...) Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal" (STJ, RHC nº 142.588/PR, 6ª Turma, Rel. o Min. Olindo Menezes, j. em 25.05.2021).

"(...) 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais,

sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP" (STJ, HC nº 561.329/SP, 6ª Turma, Rel. o Min. Nefi Cordeiro, j. em 16.06.2020, DJe 29.06.2020)

Não se desconhece, também, o fato de que, regulamentando a norma constitucional, foi editada a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das guardas civis municipais.

Todavia, referida norma não autoriza o exercício de atividades típicas das policiais por guardas municipais.

Acerca da situação analisada, o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), em voto condutor da lavra do Eminentíssimo Desembargador, Doutor Maurício Ferreira Leite, assim deliberou:

"(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

A bem da verdade, existe Recurso Extraordinário (nº 608.588/SP)contra referida decisão que ainda não foi objeto de julgamento, com reconhecimento de repercussão geral (<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3832832>), no bojo do qual o ilustre Procurador-Geral da República, salientou:

"Estão fora das atribuições constitucionais das guardas municipais as atividades que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como as de policiamento ostensivo fora desse contexto, as de polícia judiciária e a apuração de infrações penais".

Ademais, não fosse isso tudo suficiente para anulação das provas existentes, de se ressaltar ainda outro aspecto que torna viciada a prisão dos autos, qual seja, a revista pessoal sem a existência de fundada suspeita.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores têm reiteradamente deliberado pela nulidade de abordagens arbitrárias, a esmo ou com base no famigerado "tirocínio policial", com base em "nervosismo" ou situações análogas.

De igual forma, têm decidido que mera "denúncia anônima" não configura "suspeita" com força necessária para autorizar revista pessoal, ainda mais por quem não tem função policial como atividade primordial (conforme já fundamentado acima).

Nesse ponto, destaca-se o que foi decidido recentemente pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 158.580 acerca da ilicitude de provas em caso semelhante. Vejamos:

"(...) 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo

objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. (...) 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

Daí conclui-se que, seja por terem os guardas municipais agido fora de suas funções, exercendo verdadeiras atividades de investigação e patrulhamento ostensivo, ou mesmo porque ausente justa causa (fundada suspeita) para terem abordado e feito revista pessoal no denunciado, a prisão em flagrante deve ser declarada nula, com a consequente anulação das provas anexadas aos autos com o auto de prisão em flagrante ou dela decorrentes.

Ausentes indícios juridicamente válidos de autoria e materialidade, a ação penal merece o trancamento.

Ante o exposto, nos moldes da fundamentação, julgo improcedente a pretensão estatal para ABSOLVER os acusados RHUAN DE CAMARGOS, DANIEL RODRIGO FERREIRA VAZ e TIAGO ANDRÉ DOS SANTOS, já qualificados, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, razão da nulidade da prisão em flagrante e ilicitude da prova obtida.

Expeça-se o necessário, em especial os alvarás de soltura.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, bem assim daqueles armazenados para fins de contraprova, bem como a devolução dos valores apreendidos (esta última após o trânsito em julgado). Oficie-se.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo permitido nesta fase processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, providenciando-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Araras, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA